

1502134-86.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO CALVERT

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO CARVALHO LOPES JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CALVERT

Vistos.

Sérgio Carvalho Lopes Júnior, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1502134-86.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502134-86.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO CARVALHO LOPES JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO CALVERT

Vistos.

Sérgio Carvalho Lopes Júnior, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 29.9.2021, por volta das 8hs30min, no Condomínio Jundiabepa V, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas no auto de exibição e apreensão de folhas 14-15, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (folha 159), o réu apresentou defesa preliminar (folhas 164-165). Recebida a denúncia (folhas 166-167), o réu foi citado (folha [• ]).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, por fim, foi realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da exordial, com reconhecimento da qualidade e a quantidade das drogas e da reincidência do réu para recrudesimento da pena na primeira fase de dosimetria. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, pela insuficiência do conjunto probatório e com reconhecimento da ilicitude da prisão e da apreensão realizada com violação do domicílio do réu; subsidiariamente, a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, anoto que não foi realizada a formal citação do réu, o qual foi inicialmente notificado e apresentou defesa prévia, além de haver comparecido à audiência de instrução e julgamento. Entendo que inexiste qualquer prejuízo à defesa do réu, de forma que não há necessidade de realização do ato de citação nesta fase processual, conforme já decidido anteriormente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, apoiado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade do processo, em razão de ausência de citação. Inocorrência. Réu que mudou de endereço sem comunicar o juízo, tendo, porém, plena ciência da imputação que lhe foi dirigida, por meio da notificação pessoal para a apresentação da resposta escrita à acusação. Finalidade da citação alcançada. Precedentes do STJ. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada. No mérito, confissão extrajudicial corroborada pelas demais provas, sob o crivo do contraditório. Absolvição inviável. Desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Inadmissibilidade. Réu que foi surpreendido por policiais militares em plena atividade criminosa, e que foi delatado, nas duas fases do processo, pelo usuário a quem vendia droga no momento da prisão. Penas bem dosadas, em conformidade com a gravidade do caso concreto, que, por si só, todavia, não autoriza a imposição do regime inicial fechado, que fica alterado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0001567-81.2017.8.26.0548; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020)

Ainda preliminarmente, em atenção aos argumentos da defesa, anoto que o réu não foi preso no interior de seu domicílio, mas sim no interior de um condomínio popular de livre acesso. Ademais, os policiais foram claros ao descrever que o réu fugiu ao perceber a aproximação dos policiais, o que justifica a atuação dos policiais na perseguição do réu e na sua prisão em flagrante.

Neste sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU ROBERT. Pretendida, em preliminar, nulidade por violação de domicílio. No mérito absolvição por insuficiência probatória. 1) Preliminar. Descabimento. Violação de domicílio. Inocorrência. A ação policial de ingresso no condomínio particular ocorreu mediante a observância dos requisitos constitucionais, não havendo que se falar em nulidade. Ação da polícia militar legítima, sem qualquer vício de ilegalidade a maculá-la. Após surpreender Washington, na entrada do condomínio, em poder de um rádio comunicador, os agentes da lei adentraram o interior do referido local, com suspeitas relevantes, e apreenderam as porções de entorpecentes na posse do

apelante ROBERT. Crime de natureza permanente. Preceito constitucional que admite exceção à regra. Inexistência de nulidade. 2) Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. O corréu Washington se encontrava na entrada do condomínio, em poder de um rádio comunicador, objeto usualmente utilizado durante a prática de tráfico de drogas. Desse modo, os policiais adentraram o local e se depararam com o apelante ROBERT, em poder de 63 porções de cocaína, 56 invólucros de crack e 05 de maconha, além de um rádio transmissor, anotações sobre a contabilidade da mercancia ilícita e quantia em dinheiro. Na mesma ocasião, prenderam em flagrante a corré Iara, que fazia a campana nos fundos do condomínio. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0001224-84.2018.8.26.0537; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (folhas 1-2), pelo boletim de ocorrência (folhas 8-13), pelo auto de exibição e apreensão (folhas 14-15), pelas fotografias de folhas 16-18, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (folhas 19-22), pelo laudo de folhas 125-127 e pelos laudos dos exames químicos toxicológicos (folhas 186-188), com resultado positivo para Cannabis sativa L (ou "maconha"), "cocaína" e "cocaína na forma de crack".

A quantidade de drogas encontrada, a forma de armazenamento e as circunstâncias do caso concreto indicam que se destinava ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros, tipificando o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Ouvido em juízo, o réu negou a prática do delito. Disse que na data dos fatos havia acabado de acordar e seu pai o entregou R\$ 80 e uma lista de compras em um papel de caderno, razão pela qual saiu de casa em direção ao mercado. Disse que assim que deixou a sua casa, os policiais o prenderam na escadaria do condomínio. Os policiais teriam devolvido o dinheiro e a lista de compras para o pai do réu. Disse que já foi preso anteriormente pelos mesmos policiais que o prenderam nesta oportunidade e acredita que eles estão mentindo para prejudicá-lo. Disse que não permitiram que ele desse a sua versão dos fatos na delegacia de polícia.

Não obstante a negativa do réu, os demais elementos dos autos são bastante claros acerca da autoria. Com efeito, as testemunhas ouvidas foram seguras ao afirmar que o réu trazia consigo as drogas apreendidas e que as dispensou na fuga.

A testemunha Adalberto Oliveira Júnior, ouvido em juízo, afirmou que realizavam patrulhas para combater o tráfico de drogas no local dos fatos, conhecido pela venda de drogas. Disse que o réu foi avistado pulando as grades do condomínio com uma sacola verde nas mãos, razão pela qual os policiais o perseguiram (supostamente, o réu teria percebido a presença dos policiais e pretendia fugir); inicialmente o réu saltou as grades para sair do condomínio, mas adentrou novamente o condomínio para tentar evitar os policiais e foi apanhado nas escadarias do condomínio. O réu teria dispensado a sacola ao solo durante a fuga, na qual foram encontrados os entorpecentes apreendidos. Disse que o réu confirmou o tráfico de drogas informalmente. Disse que havia outras pessoas no local, inclusive funcionários do condomínio, mas não qualificaram testemunhas da apreensão de drogas.

Bruno Fernandes Galbiatti, ouvido em juízo, confirmou os fatos afirmados por

Adalberto Oliveira Júnior. Esclareceu que quando o réu pulou as grades do condomínio, viu-se diante da viatura em que estava o depoente, e por isso retornou para o interior do condomínio, pelo portão. Disse que viu que o réu trazia consigo uma sacola e que a dispensou durante a fuga; tem certeza que a sacola em que foram apreendidas as drogas é aquela que o réu trazia consigo. Havia "crack", "maconha" e "cocaína" na sacola.

Os depoimentos de policiais militares ou civis, na condição de testemunhas, deve ser considerado idôneo. Não se concebe que os agentes, sem razão aparente, pretendessem incriminar inocentes desconhecidos, de forma tão abjeta. A ilação dos agentes foi corroborada, por sinal, pela eloquente apreensão das porções de entorpecente.

Ao contrário: são testemunhas que depõem compromissadas, com presunção de veracidade por serem funcionários públicos, narrando sobre atos que, de ofício, foram praticados no exercício de suas funções.

Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". (Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 73.518, relator Ministro Celso de Mello, julgado em 26.3.1996)

"PROVA - Depoimento de policial - Valor: Não demonstrando a defesa, como lhe incumbe à luz da regra do artigo 156 do CPP, os motivos que teria o policial para, ciente da inocência do acusado, imputar-lhe falsamente a prática de crime, seu depoimento, firme e coerente naquilo que é essencial, deve ser prestigiado em detrimento da palavra do réu, principalmente quando este apresentar personalidade voltada para a prática de ilícitos penais". (Tribunal de Alçada Criminal, apelação 1.442.515/4, relator Desembargador Xavier de Souza, julgada em 29.6.2004)

Além da eloquente apreensão das drogas, os policiais foram claros ao afirmar que não têm a menor dúvida de que era o réu quem pulou o muro e quem trazia consigo a sacola em que foram encontradas as sacolas. Note-se que o réu não trouxe qualquer justificativa para a suposta farsa criada pelos policiais. Ademais, a versão apresentada pelo réu poderia ser confirmada por uma série de outras pessoas, mas a Defesa deixou de arrolar qualquer testemunha, o que enfraquece a versão isolada do réu.

Impossível, ademais, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, sob a argumentação de que as drogas não se destinavam à entrega a terceiros, mas sim ao consumo próprio, uma vez que não está em conformidade com os elementos probatórios colhidos dos autos.

A quantidade de drogas encontrada não se coaduna com o uso por apenas uma pessoa em curto espaço de tempo, tudo levando à conclusão de que estava efetivamente vendendo drogas.

Desta feita, a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, é de rigor.

Por fim, é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isso porque o réu é reincidente, o que afasta o cabimento do benefício de modo peremptório.

Ademais, a quantidade e a qualidade da droga apreendida com o réu não permitem enquadrá-lo como pequeno traficante, que é levado a praticar o crime premido pelo vício em entorpecentes ou pelas circunstâncias sociais, a quem a legislação pretendeu beneficiar com a causa de diminuição de pena em destaque.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese, a exacerbação da pena-base, ainda que se retire a menção aos maus antecedentes e, portanto, se reconheça a primariedade do paciente, não pode retroceder ao mínimo legal, uma vez que extremamente elevada a culpabilidade em razão da quantidade de droga apreendida. 3. Inviável a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 no caso concreto, pois, apesar da primariedade do acusado, a expressiva quantidade da droga indica sua participação em organização criminosa. 4. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial”. (habeas corpus 140.211, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22.9.2009)

E também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“A diminuição permitida pelo § 4º do art. 33, por outro lado, não pode ser concedida. A lei dispõe que as penas poderão ser reduzidas, o que faculta ao juiz sua concessão, após a análise do caso concreto, respeitando o princípio da individualização da pena. Na hipótese, a quantidade de droga apreendida, aliada aos informes policiais de que o apelante já se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes e ao fato de o apelante ter sido preso em companhia de usuários de drogas, demonstram a conduta social e a personalidade do agente voltada para o crime. Tais circunstâncias impedem a concessão do redutor, já que o apelante não pode ser considerado pequeno traficante”. (apelação 990.08.078177-4, relatada pelo Desembargador Galvão Bueno, julgada em 29.1.2009)

Dessa forma, impossível beneficiar o réu com a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que, mesmo primário, o réu dedica-se às atividades criminosas.

Passo à dosimetria da pena, o que faço nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e dando preponderância à natureza e à quantidade da substância, à personalidade e à conduta social do agente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, pondero que a qualidade da droga apreendida e os maus antecedentes do réu devem ser considerados para o recrudescimento da pena-base.

Com efeito, o artigo 42 da Lei 11.343/06 determina que seja considerada a qualidade da droga para fins de estabelecimento da pena-base na primeira fase da dosimetria. Esta determinação legal, aliada à grande elasticidade do preceito secundário do tipo criminoso do artigo 33, caput, desta lei, indica que o juiz deverá aplicar penas diferentes para os diferentes tipos de substâncias entorpecentes, de acordo com a lesividade da droga.

No sentido de apenarem-se de forma diferenciada os traficantes de acordo com a quantidade e a qualidade da droga comercializada, dando efetividade ao princípio da individualização da pena, já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“A despeito do sustentado pela defesa, o magistrado de primeiro grau fundamentou exaustivamente a fixação da pena base do réu acima do mínimo legal, pautando-se no art. 42 da Lei 11.343/06, observando a quantidade e natureza da droga, bem como a

conduta social do acusado. Tais circunstâncias extrapolam o já previsto pelo tipo e devem ser consideradas pelo magistrado quando da fixação das penas, como disposto no supramencionado artigo, pois no presente caso extrapolam o já previsto pelo tipo.

Assim, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo.

Repise-se, o art. 42 da Lei 11.343/06 é expresso ao determinar que a quantidade e a natureza do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena base". (apelação 0001695-14.2013.8.26.0396, relatada pelo Desembargador Edison Brandão, julgada em 9.9.2014, extraído do voto relator)

No caso dos autos, com o réu foram apreendidas porções de "crack", droga que pode, sem qualquer receio de erro, ser apontada como a mais lesiva entre todas aquelas que são comumente comercializadas pelos traficantes, a qual determina grave dependência física e psicológica, afeta de forma agressiva o sistema nervoso central e acarreta em graves sequelas pessoais aos usuários, determinado comportamentos agressivos e antissociais por parte do usuário, de forma a causar danos pessoais, sociais e familiares graves e perenes.

Impossível apenar da mesma forma o agente que vende "crack" e aquele que vende outras drogas de potencial lesivo reconhecidamente menor.

Desta forma, em atenção à qualidade da droga comercializada pelo réu, recrudescer sua pena-base em 2 (dois) anos.

Outrossim, o réu é useiro e vezeiro nos corredores judiciais, contando com miríades de processos criminais e mais de uma condenação definitiva, conforme se constata da sua longa folha de antecedentes (folhas 78-81 do apenso). Os péssimos antecedentes do réu e o fato de viver constantemente às margens da lei levam à maior reprovação de sua conduta, independentemente da reincidência, que será considerada na segunda fase.

Dessa forma, o reconhecimento dos maus antecedentes do réu servirá para o aumento de sua pena-base em mais 1 (um) ano, a qual fixo, portanto, em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a presença da circunstância agravante relativa à reincidência do réu (folhas 78-81 do apenso), a qual acarretará o agravamento da pena no patamar de 1/6 (um sexto), passando a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

À mingua de outras causas modificativas, torno definitiva as penas fixadas acima.

A pena pecuniária será calculada no patamar mínimo legal, ante a ausência de dados sobre a capacidade financeira do réu.

A pena privativa de liberdade imposta ao réu deverá ser cumprida em regime inicial fechado, tendo em vista a quantidade da pena imposta, a consideração negativa das circunstâncias judiciais e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar Sérgio Carvalho Lopes Júnior, qualificado nos autos, às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nego ao réu o direito de interpor recurso de apelação em liberdade, uma vez que

remanescem íntegros os fundamentos que determinaram a sua prisão cautelar, os quais, ademais, foram reforçados pelo presente decreto condenatório. Outrossim, a quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao réu, recomenda a sua manutenção no cárcere para garantia da aplicação da lei penal, além de sua reiteração criminosa demonstrar a segregação cautelar do réu para manutenção da ordem pública.

Recomende-se o réu na prisão.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03, condeno, ainda, o réu, ao pagamento das custas judiciais, no valor de 100 (cem) Ufesps. Observem-se, no entanto, as disposições do artigo 12 da Lei 1.060/50.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Mogi das Cruzes, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA